

1500352-65.2020.8.26.0297

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... a responsabilidade do filho Diego pela prática do tráfico de drogas.

Logo, diante do farto conjunto probatório, evidencia-se a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo réu Diego.

Percebe-se, portanto, que a tese de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo suscitada em defesa não merece amparo. O fato de ser usuário de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500352-65.2020.8.26.0297 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500352-65.2020.8.26.0297

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 1046/2020 - 1º Distrito

Policial de Jales, 156/2020 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HENRIQUE AMANCIO DE LIMA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

DIEGO HENRIQUE AMÂNCIO DE LIMA (filho de Sidnei Henrique de Lima e Elizangela Amâncio Belancieri, nascido em 10/01/2001, natural de Jales - SP, RG 52844878) foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e CÉSAR FÉLIX DOS SANTOS (filho de Jozias Felix dos Santos e Auseli Franca dos Santos, nascido em 03/02/1977, natural de Jales-SP, RG 29543335) como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 03 de março de 2020, por volta da 18hrs, na Rua dos Pioneiros, nº 1107, Jardim Monterey, nesta cidade e Comarca de Jales-SP:

a) DIEGO, nas imediações da Igreja São João Batista, Unidade de Saúde da Família Rural "Dr. José Cícero Fontes", Faculdade de Tecnologia - FATEC e Salão do Reino

das Testemunhas de Jeová, vendeu, guardava e tinha em depósito para o fornecimento a terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, sob a forma de "crack", embalada em plástico branco, com peso líquido de 0,10 gramas; 06 (seis) porções de cocaína, sob a forma de "crack", embaladas separadamente, prontas para a venda, com peso líquido de 0,93 gramas; e 02 (duas) porções da substância Cannabis Sativa L, contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", embaladas em plástico amarelo, com peso líquido de 5,11 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

b) CÉSAR adquiriu, trazia consigo e transportava, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, sob a forma de "crack", embalada em plástico branco, com peso aproximado de 0,10 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobreveio decisão cumprindo determinação da liminar concedida no Habeas Corpus 2068678-38.2020.8.26.0000, que concedeu liberdade provisória ao réu Diego (p. 242). Notificados (p. 209 e 450), os réus defenderam-se preliminarmente por intermédio de advogados constituídos (p. 273/276 e 288/307).

Recebeu-se a denúncia em 05/05/2020 (p. 323).

Os réus foram citados (p. 448 e 452).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação (Francis Rodrigo Nalle e Diego Correa Alonso) e duas testemunhas de defesa (Ederson Henrique Alves Gonçalves e Sidnei Henrique de Lima). Por fim, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. Quanto à pena, com relação ao réu Diego, opinou pela aplicação acima do mínimo legal, tendo em vista a natureza da droga apreendida e a personalidade do réu, bem como a incidência da atenuante da menoridade relativa e da causa de aumento de pena do art. 40, III, da LD. Refutou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da LD, entendendo pertinente a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento de pena. No tocante ao réu César, porque ostenta maus antecedentes e é reincidente, pugnou pela fixação de pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e comparecimento em programa educativo, pelo prazo de dez meses (p. 630/649).

A defesa de César, em alegações finais, requereu a absolvição do réu por atipicidade material da conduta (princípio da insignificância), além de pugnar pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do tipo penal. Ainda, pediu a aplicação da pena de advertência (p. 654/665).

Por sua vez, a defesa de Diego, preliminarmente, arguiu nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória. Também pleiteou a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, "caput", da LD, além de refutar a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III, da LD. Subsidiariamente postulou a fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da LD, em fração de 2/3. No mais, entendeu cabível a aplicação do regime inicial aberto e a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade. Por fim, pediu a restituição do valor e celular apreendidos (p. 669/716).

É o relatório.

Afasta-se a preliminar de nulidade da prova obtida nos autos, em razão da ilicitude do meio, ou seja, busca domiciliar na residência do réu Diego. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao Tema 280 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

(RE nº 603.616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015).

No caso, inviável o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes das buscas

realizadas na residência de Diego, pois a dinâmica dos fatos não deixa dúvida de que ele foi abordado e preso em situação de flagrância e, por isso, a atuação dos agentes públicos que ingressaram no imóvel não se mostra ilegal ou ilícita. Mormente porque os policiais militares lograram êxito em abordar usuário de drogas em frente à residência do réu, logo depois de ter adquirido entorpecente - fato admitido pela usuária quando da abordagem policial. Portanto, é evidente que haviam fundadas suspeitas para ingressarem no imóvel.

Registre-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e repressão.

Por essas razões, não há ilegalidade ou ilicitude na busca realizada no domicílio do réu.

Quanto ao mérito, o pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, imputado ao réu Diego, e do crime de posse de entorpecente para consumo próprio, imputado ao réu César, está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01), pelo boletim de ocorrência (p. 10/13), pelo auto de exibição e apreensão (p. 14/15), pelos laudos de constatação (p. 28/31 e 32/35), pelo laudo pericial nos objetos (p. 103/105), pelos laudos de exame químico-toxicológico (p. 106/108 e 109/111) - que atestaram que as drogas apreendidas tratavam-se "cocaína" e Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha" -, pelo relatório do celular (p. 475/483 e 486/479), bem como pela prova oral.

A autoria delitiva é certa.

O réu Diego, interrogado em juízo, negou a prática do tráfico de entorpecentes. Admitiu a propriedade das porções de "maconha" guardadas na geladeira. A "maconha" era para consumo próprio. Não tem conhecimento das porções de "crack". Não conhece César e nem vendeu drogas para ele. Seu pai admitiu a propriedade do "crack". Estava saindo de casa quando abordado. Trabalhava como servente de pintor na data dos fatos. Não vendeu droga para César. A quantia em dinheiro apreendida é fruto de seu trabalho. Juntou a quantia para fazer a festa de aniversário do filho. A quantia estava guardada no guarda-roupas. O papel alumínio não estava no guarda-roupas. Iria à casa de sua mãe no momento da abordagem. Trabalhou no dia da ocorrência. O policial Diego ingressou em sua residência junto com Francis. Sua esposa chegou ao imóvel, mas não acompanhou as buscas. Atualmente trabalha com venda de roupas. Fazia uso de "maconha". Seu pai é viciado desde pequeno e mora em outro bairro.

O réu César, interrogado em juízo, admitiu que portava a porção de "crack". Comprou a porção de "crack" com o menor "DJ" na linha de trem. Rumou ao bairro Vila União. Não comprou nada com o réu Diego. Fumou uma pedra de "crack", no bosque, antes de passar na residência da noiva. Ergueu a mão para a noiva e pediu para que ela retirasse as medidas protetivas. Dispensou o pino de "crack" antes de ser abordado pelos policiais. Portava uma faca, mas não ameaçou a noiva com o objeto. Não disse, na delegacia, que comprou a droga de Diego. Não passou na residência de Diego. Estava sob efeito de álcool e drogas no dia dos fatos. Já foi internado. Consumia "crack" diariamente. Foi apresentado na delegacia por causa do descumprimento da medida protetiva.

Francis Rodrigo Nalle, policial militar, disse que foram acionados, via COPOM, para atender ocorrência de ameaça contra mulher. A vítima relatou que César ameaçou-a e estava na Vila União para comprar "crack". Abordaram César na Rua dos Pioneiros, sendo com ele localizadas uma faca e uma porção de "crack". César admitiu ter comprado o entorpecente de Diego. Diego é conhecido nos meios policiais por traficar entorpecentes, inclusive, apreenderam-no com mais de um quilo de drogas posteriormente. Com a autorização da esposa de Diego, seu parceiro adentrou a residência do réu, tendo encontrado porções de "crack" e seis reais - conforme mencionado por César, valor pago pela porção de "crack". Dentro da residência, encontraram mais de três mil reais, maconha na geladeira e objetos para embalagem de entorpecente. Conhecia César por ser usuário de "crack" e Diego por várias "denúncias" por tráfico de drogas. Diego é bastante conhecido na Vila União pelo tráfico de drogas. A esposa de Diego acompanhou as buscas na residência. Permaneceu

com o réu na calçada. Diego encontrava-se na calçada quando da abordagem. O réu negou possuir entorpecente no interior do imóvel. Diego reconheceu a propriedade da "maconha" para uso. Não sabe se Diego tinha trabalho lícito. César estava lúcido no momento da abordagem. César tinha alcunha de "Pastor".

Diego Correa Alonso, policial militar, atendeu ocorrência envolvendo violência doméstica. A vítima disse que César havia acabado de sair. O réu é conhecido nos meios policiais por ser usuário de "crack". Em diligência pela Vila União, visualizaram César saindo de uma casa na Rua dos Pioneiros. Abordaram-no, sendo como ele encontrada uma faca e uma porção de "crack". César respondeu que havia acabado de comprar a droga de Diego. Abordaram Diego na calçada de sua residência, mas nada de ilícito encontraram com ele. Autorizados pela esposa de Diego, realizaram buscas no domicílio. Localizou seis porções de "crack", "maconha" e quantia em dinheiro no imóvel de Diego. Conduziram-nos à delegacia. César foi abordado na Rua dos Pioneiros, próximo à residência de Diego. Diego estava na calçada durante as buscas no domicílio. Acredita que a esposa de Diego tenha acompanhado as buscas. O pai de Diego chegou ao local assumindo a propriedade da droga encontrada. Recorda-se que algumas porções de drogas foram encontradas no corredor da casa e na geladeira. Diego negou a propriedade do entorpecente. Não sabe se o pai de Diego é usuário. César aparentava estar lúcido quando da abordagem. Com relação a César, lavraram ocorrência por descumprimento de medida protetiva.

Sidnei Henrique de Lima, pai do réu Diego, afirmou que o entorpecente encontrado na casa do filho lhe pertence. É usuário de drogas. A droga estava no corredor do fundo. Viu os policiais na residência do filho quando voltava do bar. Trabalha como "chapa". Não mora junto com Diego. Mora no bairro Paraíso. Pulou o muro da casa do filho para esconder a droga no corredor. Escondeu o "crack". Não se recorda quanto de "crack" escondeu. Não se lembra como estava embalada a droga. As outras drogas encontradas eram suas também.

A testemunha Ederson Henrique Alves Gonçalves em nada pode contribuir para o desenrolar do processo, pois não presenciou os fatos.

Como se nota a versão de Diego é inverossímil. Embora negue o envolvimento com o tráfico de droga, constata-se, na realidade, que as substâncias apreendidas se destinavam à aquisição por terceiros.

De acordo com os policiais Francis e Diego, César havia acabado de sair da residência da ex-esposa após ameaçá-la. Como é usuário de drogas conhecido dos meios policiais, procuraram-no pelo bairro da Vila União, tendo visto o momento em que ele saiu de uma residência. Durante a abordagem, encontraram uma porção de "crack" com o usuário, que admitiu ter comprado a droga de Diego, por seis reais. Ouvido em delegacia, César admitiu ter comprado a porção de "crack" de Diego, pelo valor de seis reais. Tal versão, em que pese ter sido modificada em juízo, encontra-se amparada pelas declarações das testemunhas Francis e Diego - pessoas que acompanhavam César no momento da abordagem.

Registre-se que a alteração de declarações por parte de usuários, na tentativa de eximir traficantes de responsabilidade pela venda de drogas, é comum, porque receiam represálias - principalmente, levando-se em consideração que César encontra-se preso.

Ademais, conforme relatos dos policiais, no corredor da residência de Diego, foram encontradas seis porções de "crack" - embaladas de forma semelhante à adquirida por César -, além da exata quantia de seis reais em moedas - quantia paga pela porção de "crack" adquirida momentos antes pelo usuário.

Chama atenção, ainda, o fato de terem sido apreendidos, na residência de Diego, objetos típicos para embalagem de entorpecente e grande quantia em dinheiro (mais de três mil reais) fracionada em diversas notas e moedas.

Ademais, não merece credibilidade a versão apresentada pela testemunha Sidnei. Apesar de ter assumido a propriedade dos entorpecentes localizados na residência de Diego, não soube esclarecer exatamente quais os tipos e a forma como as drogas foram localizadas. Além do mais, declarou que mora em outro bairro, não sendo crível que tenha vindo à casa de Diego somente para esconder os entorpecentes. Portanto, é nítido o intuito do pai em eximir a responsabilidade do filho Diego

pela prática do tráfico de drogas.

Logo, diante do farto conjunto probatório, evidencia-se a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo réu Diego.

Percebe-se, portanto, que a tese de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo suscitada em defesa não merece amparo. O fato de ser usuário de drogas não exclui a possibilidade de, também, se dedicar à comercialização do entorpecente. Como se sabe, muitos dependentes passam a traficar como forma de sustentar o próprio vício. Além do mais, o réu apresentou-se calmo, com fala articulada e raciocínio coerente, não demonstrando indícios de que seja usuário severo de drogas.

Afasta-se a causa especial de aumento de pena descrita no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06. Segundo o laudo de p. 112/115, o tráfico de entorpecentes foi cometido nas imediações de uma igreja, instituição de ensino e uma entidade de atendimento à saúde.

O Superior Tribunal possui o entendimento de que "Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância." (HC n. 407.487/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/12/2017).

Desse modo, para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, basta que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações das localidades relacionadas no dispositivo legal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei.

No entanto, em matéria penal, não se admite analogia "in malam partem". Assim, não há como se inserir no rol das majorantes o fato de o agente ter cometido o delito nas dependências ou nas imediações de igreja, porque a hipótese não foi contemplada pelo legislador. Logo deve ser afastada a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DA REFORMA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016.

2. Cuida a espécie de recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concedeu a segurança pleiteada pelo recorrido, policial militar inativo do referido ente federado, a fim de assegurar-lhe o direito de não ter sua aposentadoria cassada com espeque na regra contida no art. 92, I, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo, ao disciplinar os efeitos da condenação, autoriza apenas a perda do cargo, da função pública e do mandato eletivo, nada dispondo sobre cassação de aposentadoria civil ou militar.

3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem" (HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 1.683.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2018.

4. Inexistindo controvérsia sobre o fato de a pretérita atividade do recorrido nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal não se confundir com o seu posterior status de integrante da reserva remunerada, cumpre afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para se atingir o militar já reformado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal.

5. "Atualmente, prevalece nesta Corte a orientação segundo a qual não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019). Nessa mesma linha, "A previsão legal, no entanto, nada diz a respeito da cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma, caso se trate de servidor público militar. Por se tratar de norma penal punitiva, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sob pena de violação ao princípio que proíbe o emprego da interpretação analógica in malam partem, como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa" (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2018).

6. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

7. Recurso especial do Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1576159/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ademais, em que pese a existência de instituição de ensino e uma entidade de atendimento à saúde nas imediações do local em que o réu desempenhava o tráfico, os fatos ocorreram durante o período de pandemia da COVID-19 (03/03/2020), momento em que grande parte das atividades coletivas encontravam-se suspensas. Portanto, afasta-se a causa de aumento de pena.

Noutro giro, a prática do porte de entorpecentes para consumo próprio, por parte de César, está bem demonstrada nos autos.

Isso porque o réu César admitiu a propriedade da porção de "crack", com ele encontrada no momento da abordagem policial, explicando que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio.

Saliente-se que a confissão do réu se encontra amparada pelos relatos das testemunhas Francis e Diego, os quais declararam que a droga foi apreendida em posse de César, tendo o mesmo confessado que havia acabado de adquirir de Diego, por seis reais, para consumo próprio.

Há de se consignar que, ao contrário do que pretende a defesa, é inviável o reconhecimento de atipicidade material da conduta.

É que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o princípio da insignificância não incide sobre o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. (AgRg no RHC 147158 / SP, 6ª Turma do STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 25/05/2021).

Igualmente não há de se falar em inconstitucionalidade do art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois - a despeito de existir recurso extraordinário em julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o tema - o tipo penal originou-se de devido processo legislativo e ampara direito fundamental à saúde pública. Logo, por ora, não se evidencia qualquer inconstitucionalidade.

Assim, diante do conjunto probatório, não há dúvidas de que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia: a) Diego vendeu, guardava e tinha em depósito para o fornecimento a terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, sob a forma de "crack", embalada em plástico branco, com peso líquido de 0,10 gramas; 06 (seis) porções de cocaína, sob a forma de "crack", embaladas separadamente, prontas para a venda, com peso líquido de 0,93 gramas; e 02 (duas) porções da substância Cannabis Sativa L, contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", embaladas em plástico amarelo, com peso líquido de 5,11 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e; b) César adquiriu, trazia consigo e transportava, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, sob a forma de "crack", embalada em plástico branco, com peso aproximado de 0,10 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar. Fatos que se amoldam, respectivamente, aos tipos penais previstos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 (Diego) e art. 28 da Lei nº 11.434/06 (César).

Configurada a responsabilidade penal e a autoria dos crimes, passa-se à individualização da pena.

Com relação a DIEGO HENRIQUE AMÂNCIO DE LIMA, na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o réu, tecnicamente, não ostenta maus antecedentes criminais. Nota-se pela certidão de objeto e pé de p. 511/512 que possui condenação criminal por tráfico de drogas (Processo nº 1500295-12.2020.8.26.0632, da 1ª Vara Criminal de Jales-SP), porém se trata de fato posterior ao analisado nos autos e sem notícia de trânsito em julgado. Desse modo, inauguro a pena base no mínimo legal, fixando a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem reconhecidas. Por outro lado, reconheço a circunstância atenuante da menoridade (CP, 65, I), pois o réu possuía 19 anos de idade na data dos fatos (p. 07). Contudo, tendo-se em vista que a pena, nesta fase, não pode ser conduzida aquém do mínimo legal (STJ, 231), mantém-se a pena intermediária no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena a serem analisadas. Por outro lado, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porque, o réu é primário e não há indícios de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Consigne-se que este juízo vinha levando em consideração a reiteração na prática do tráfico de entorpecentes – ainda que em processamento – para afastar o privilégio legal. Todavia, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento da Quinta e Sexta Turmas – para alinhá-las às decisões do Supremo Tribunal Federal –, no sentido de que "(...) a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal" (HC 664.284/ES, Quinta Turma do STJ, rel. Ministro Riberio Dantas, ocorrido em 21/9/2021, DJe 27/09/2021), E, também, "(...) A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado" (RHC 210056 AgR, da Segunda Turma do STF, rel. Ricardo Lewandowski, julgado em 09/03/2022). Desse modo, diminuo a pena aplicada ao tráfico em 2/3, fixando a pena definitiva em pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pena de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, porque a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e o réu é tecnicamente primário. Consigne-se que a equiparação à hediondez do tráfico privilegiado foi afastada por decisões do Superior Tribunal Federal (HC 118.533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016) e do Superior Tribunal de Justiça (Tese Firmada no Tema 600 dos Recursos Repetitivos, publicada em 29/11/2016). Portanto, não deve incidir a determinação do § 1º do artigo de 2º da Lei nº 8.072/90.

Deixo de computar o período de prisão provisória para fins de detração determinado pelo §2º do art. 387 do CPP, ante a fixação o regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Substituto a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em

vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), o réu não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º): prestação pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Quanto a CÉSAR FÉLIX DOS SANTOS, sopesadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), verifica-se que o réu possui maus antecedentes criminais (p. 517/520).

Constata-se, ainda, que César é reincidente, conforme se depreende da certidão de objeto e pé de p. 523/524 (processo nº 0002659-86.2008.8.26.0297 da extinta 4ª Vara Criminal da Comarca de Jales, em cumprimento de pena p. 556). Todavia, há de reconhecer a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP). Como as circunstâncias (agravante e atenuante) são preponderantes, opera-se a compensação entre elas (CP, 67).

Desta forma, entendo que a pena de prestação de serviços à comunidade é a que melhor se adequa ao caso, mormente no que tange à maior eficácia para o desestímulo ao uso de entorpecentes. Diante dessas considerações, aplico ao réu a sanção de prestação de serviço à comunidade, a ser especificada no momento da execução, pelo prazo de 05 (cinco) meses (art. 28, II c.c. §§ 3º e 5º da Lei nº 11.343/06).

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno:

a) DIEGO HENRIQUE AMÂNCIO DE LIMA (filho de Sidnei Henrique de Lima e Elizangela Amâncio Belancieri, nascido em 10/01/2001, natural de Jales - SP, RG 52844878), como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e à pena de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária consistente no pagamento de 03 (três) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução;

b) CÉSAR FÉLIX DOS SANTOS (filho de Jozias Felix dos Santos e Auseli Franca dos Santos, nascido em 03/02/1977, natural de Jales-SP, RG 29543335), como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviço à comunidade, a ser especificada no momento da execução, pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Condeno os réus no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios gratuidade da justiça.

Poderão os condenados recorrerem em liberdade, pois as penas aplicadas incompatibilizam-se com a segregação cautelar.

Quanto à quantia (R\$3.192,30) e ao objeto (celular "Samsung") - constante do auto de apreensão e exibição de p. 14/15 -, considerando que o condenado Diego não comprovou a origem lícita do valor e do celular, bem como por guardarem correlação com crime de tráfico de drogas, decreto-lhes o perdimento em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

Há de se mencionar que a destinação dos demais objetos apreendidos já foi analisada

em decisão de p. 379.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Consigne-se que a destruição das drogas apreendidas já foi determinada pela decisão de p. 146. Após o trânsito em julgado, deverão ser destruídas as amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos (art. 72 da Lei nº 11.343/06 com a redação dada pela Lei nº 12.961/14).

Com o trânsito em julgado: expeçam-se guias de recolhimento para execução das penas (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral dos apenados para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); remeta-se ao SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) a relação de bens declarados perdidos em favor da União, indicando o local em que se encontra e o órgão em cujo poder esteja, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente (art. 63, § 4º da Lei nº 11.343/06); e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA